GRUPO II – CLASSE I – Plenário
TC 028.814/2022-3
Natureza: Pedido de Reexame.
Órgão/Entidade: Ministério da Saúde.
Responsáveis: Adriane Maria Pignatti (666.542.461-87); Fib Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A (23.706.333/0001-36); Global Gestão Em Saúde S.A. (10.375.666/0001-88); Gustavo Apoliano Mesquita (893.810.331-53); P.B. Investments Empresarial S/A (07.376.572/0001-19); Precisa - Comercialização de Medicamentos Ltda (03.394.819/0001-79); Roberto Ferreira Dias (086.758.087-98).
Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde; Banco Central do Brasil (00.038.166/0001-05); Convida Refeições Ltda (05.599.283/0001-53); Departamento de Polícia Federal (00.394.494/0014-50); Fib Bank Garantia de Finanças Fidejussórias S/A (23.706.333/0001-36); Global Gestão Em Saúde S.A. (10.375.666/0001-88); P.B. Investments Empresarial S/A (07.376.572/0001-19); Precisa - Comercialização de Medicamentos Ltda (03.394.819/0001-79); Presta Construtora e Servicos Gerais Ltda (02.282.245/0001-84); Procuradoria da República No Distrito Federal - Mpf (26.989.715/0012-65); Secretaria-executiva da Controladoria-geral da União; Secretaria-executiva do Ministério da Saúde (00.394.544/0173-12).
Representação legal: Jose Orismo Pereira (134315/OAB-SP), representando Fib Bank Garantia de Fiancas Fidejussórias S/A; Felipe Carvalho de Novaes (37173/OAB-PE), representando Tiago Pontes Queiroz; Fábio Nunes Bandeira de Melo (4331/OAB-AM), Bruno Vieira da Rocha Barbirato (6975/OAB-AM) e outros, representando Adele Schwartz Benzaken; Pablo Rangell Mendes Rios Pereira (40586/OAB-DF), representando Gustavo Apoliano Mesquita; Anderson de Oliveira Lima Goncalves, Renata Rita Volcov (274717/OAB-SP) e outros, representando Convida Refeicoes Ltda; Daiana Lacerda de Morais Melo Praxedes (31531/OAB-GO) e Jeane Cristina Machado (27245/OAB-GO), representando Presta Construtora e Servicos Gerais Ltda; Pablo Rangell Mendes Rios Pereira (40586/OAB-DF), representando Adriane Maria Pignatti.

SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO. IRREGULARIDADES EM LICITAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PANDEMIA. CONHECIMENTO. CONTRATAÇÃO DE LICITANTE NÃO COMPROVADAMENTE DETENTORA DOS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO TÉCNICA E PERTENCENTE À EMPRESA IMPEDIDA DE LICITAR. FRAUDE À LICITAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE DAS EMPRESAS ENVOLVIDAS. INABILITAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS. MULTAS. PEDIDO DE REEXAME. CONHECIMENTO. NEGATIVA DE PROVIMENTO DE UM E PROVIMENTO DE OUTRO.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77660553.

RELATÓRIO

Adoto, como relatório, instrução elaborada pela Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) - peças 387-388:

INTRODUÇÃO

1. Trata-se de pedido de reexame interposto por Adriane Maria Pignatti (peça 355) e Gustavo Apoliano Mesquita (peça 359) contra o Acórdão 1.912/2024-TCU-Plenário (peça 305, rel. Min. Vital do Rêgo).

1.1. A deliberação recorrida apresenta o seguinte teor:

> *9.1. conhecer da representação;*
>
> *9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis Gustavo Apoliano Mesquita e Adriane Maria Pignatti, aplicando-lhes, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso II, do Regimento Interno, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;*
>
> *9.3. considerar graves as infrações cometidas pelos responsáveis Gustavo Apoliano Mesquita e Adriane Maria Pignatti e, com base no art. 60 da Lei 8.443/1992, inabilitá-los, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal;*
>
> *9.4. aplicar multa ao responsável revel Roberto Ferreira Dias, com base no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso II, do Regimento Interno, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;*
>
> *9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 e do art. 217 do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas constituídas pela presente deliberação em até 36 parcelas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais;*
>
> *9.6. determinar ao Ministério da Saúde, com base no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, que proceda ao desconto integral ou parcelado das dívidas referidas nos itens 9.2 e 9.4 da presente deliberação nos vencimentos, salários ou proventos dos responsáveis Gustavo Apoliano Mesquita (CPF 893.810.331-53), Adriane Maria Pignatti (CPF 666.542.461-87) e Roberto Ferreira Dias (CPF 086.758.087-98), observados os limites previstos na legislação pertinente, caso não providenciado o recolhimento espontâneo no prazo fixado;*
>
> *9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992;*
>
> *9.8. declarar, com base no art. 46 da Lei 8.443/1992, a inidoneidade das empresas Global Gestão em Saúde S.A. (CNPJ 10.375.666/0001-88), OVS Importadora Ltda. (CNPJ*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77660553.

03.394.819/0001-79) - atual denominação da empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ 03.394.819/0001-79) - e da sua filial OVS Importadora Ltda. (CNPJ 03.394.819/0005-00) para participarem, por três anos, de licitação na Administração Pública Federal ou que utilize recursos federais;

9.9. declarar, com base no art. 46 da Lei 8.443/1992, a inidoneidade das empresas FIB Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A (CNPJ 23.706.333/0001-36) e P. B. Investment Empresarial S/A - Profit Bank (CNPJ 07.376.572/0001-19) para participarem, por três anos, de licitação na Administração Pública Federal ou que utilize recursos federais;

9.10. acolher as justificativas apresentadas pelos defendentes Pablo Guedes de Andrade Fenelon, Tiago Pontes Queiroz, Gerson Fernando Mendes Pereira, Adele Schwartz Benzaken, Manoel Carlos Alves Braga, Regina Célia Silva Oliveira e Renata Marques Santana, bem como pelas empresas Convida Refeições Ltda. e Presta Construtora e Serviços Gerais Ltda., excluindo as suas responsabilidades no processo;

9.11. enviar cópia desta deliberação:

9.11.1. ao Presidente do Senado Federal, Senador Rodrigo Pacheco;

9.11.2. aos Senadores Omar Aziz, Rogério Carvalho e Humberto Costa;

9.11.3. ao Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, do Ministério Público junto ao TCU;

9.11.4. à Procuradoria da República no Distrito Federal;

9.11.5. ao Ministério da Saúde;

9.11.6. à Controladoria-Geral da União;

9.11.7. ao Departamento de Polícia Federal;

9.11.8. ao Banco Central do Brasil;

9.12. juntar cópia da presente deliberação aos autos do TC 038.711/2021-4;

9.13. arquivar este processo.

HISTÓRICO

2. Em 14/9/2021, foi aprovada Solicitação do Congresso Nacional, de autoria dos Senadores Rogério Carvalho (PT/SE) e Humberto Costa (PT/PE), proveniente da chamada "CPI da Pandemia", autuada no TC 038.711/2021-4, que demandou a realização de fiscalização pelo Tribunal de Contas da União nos contratos da Administração Pública Federal em que a empresa FIB Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A figurasse como garantidora, dado que pairavam inúmeras suspeitas contra tal instituição, como a existência de capital social fictício.

2.1. Naqueles autos, foi proferido o Acórdão 2.373/2022-TCU-Plenário, rel. Min. Vital do Rêgo, com a informação de que haviam sido identificados quatro contratos administrativos pelo Ministério da Saúde (MS), em que foram aceitas cartas de fiança fidejussórias em garantia, não obstante consistirem em instrumentos não admitidos pelo art. 56, § 1º, da Lei 8.666/1993, sendo que três deles garantidos pela FIB Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A, enquanto outro pela P.B. Investment Empresarial S/A – Profit Bank.

2.2. Foi determinada a autuação de apartado – o presente processo –, para apurar os indícios de irregularidade relacionados à condução e homologação dos Pregões Eletrônicos SRP 53/2018 e SRP 81/2020, conduzidos pelo MS, bem como relativos à formalização, gestão e fiscalização dos

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77660553.

Contratos MS 249/2018, 152/2019 e 316/2020, e à aceitação da garantia na forma de carta de fiança fidejussória apresentada pela FIB Bank no âmbito do Contrato 29/2021.

2.3. Ato contínuo, realizou-se audiências de dez agentes do Ministério da Saúde (peças 25 a 34, 241 e 253), bem como oitivas das firmas Global Gestão em Saúde S/A (peça 26, 240 e 257), OVS Importadora Ltda (Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda) (peças 37), FIB Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A (peça 264, 272, 275), P.B. Investment Empresarial S/A (peça 265, 271, 276), Convida Refeições Ltda (peça 283) e Presta Construtora e Serviços Gerais Ltda (peça 284).

2.4. Dentre os agentes do Ministério da Saúde chamados em audiência, apenas o Sr. Roberto Ferreira Dias, então Diretor do Departamento de Logística em Saúde da Secretaria Executiva do MS, ordenador de despesa e gestor do Contrato 316/2020, não apresentou suas razões de justificativa. Dentre as empresas chamadas em oitiva, a Global Gestão em Saúde S/A e a OVS Importadora Ltda não se manifestaram.

2.5. Após analisar todos os esclarecimentos e documentos trazidos aos autos, a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), em sua manifestação conclusiva (peça 298), propôs conhecer da representação, e:

> *a) inabilitar para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, o Sr. Gustavo Apoliano Mesquita, então Pregoeiro do Pregão Eletrônico SRP 53/2018, e a Sra. Adriane Maria Pignatti, Diretora do Departamento de Logística em Saúde do Ministério da Saúde, substituta, que homologou, em 22/11/2018, o resultado do Pregão Eletrônico SRP 53/2018;*
>
> *b) aplicar a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 ao Sr. Gustavo Apoliano Mesquita, à Sra. Adriane Maria Pignatti, ao Sr. Roberto Ferreira Dias, ao Sr. Gerson Fernando Mendes Pereira, então ocupante da função de Diretor Substituto do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis do HIV/Aids e das Hepatites Virais, ao Sr. Pablo Guedes de Andrade Fenelon, Pregoeiro do Pregão Eletrônico SRP 81/2020 e à Sra. Regina Célia Silva Oliveira, fiscal do Contrato 29/2021;*
>
> *c) declarar a inidoneidade das empresas Global Gestão em Saúde S.A., OVS Importadora Ltda. (atual denominação da empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda.), e de sua filial, em face do cometimento de fraude à licitação no Pregão Eletrônico SRP 53/2018 e Ata de Registro de Preços 115/2018.*

2.6. Em relação às empresas emitentes de "cartas de fiança fidejussória" (FIB Bank e Profit Bank), a unidade técnica entendeu haver reprovabilidade da conduta ilícita, mas entendeu não ser possível as declarar inidôneas, em razão de tal possibilidade não haver sido acolhida em precedentes jurisprudenciais da Corte de Contas e da ausência de expressa previsão legal que permita a adoção da medida punitiva pelo TCU (peça 298, p. 90-91).

2.7. O relator, Min. Vital do Rêgo, discordou parcialmente da unidade técnica, entendendo por não aplicar multas ao Sr. Gerson Fernando Mendes Pereira e à Sra. Regina Célia Silva Oliveira, bem como entendendo haver elementos suficientes para que a participação das empresas emitentes de cartas de fiança fidejussórias fosse tipificada como fraude à contratação, sendo pertinente aplicar-lhes a sanção de inidoneidade disposta no art. 46 da Lei 8.443/1992 (peça 306).

2.8. Tais entendimentos foram acolhidos pelo Acórdão 1.912/2024-TCU-Plenário, rel. Min. Vital do Rêgo (peça 305), que ainda deliberou por acolher as justificativas do Sr. Pablo Guedes de Andrade Fenelon, Pregoeiro do Pregão Eletrônico SRP 81/2020.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77660553.

2.9. Nesse momento a Sra. Adriane Maria Pignatti e o Sr. Gustavo Apoliano Mesquita insurgem-se contra a citada deliberação por meio de pedido de reexame (peças 355 e 359).

ADMISSIBILIDADE

3. Reitera-se a proposta de conhecimento do recurso, nos termos do exame de admissibilidade de peça 368 e 369 e do despacho de peça 379.

EXAME DE MÉRITO

4. ***Delimitação***

4.1. O presente exame contempla as seguintes questões:

a) ausência de dolo, falha grave ou erro grosseiro;

b) quebra de isonomia em relação a condutas de outro agente;

c) desarrazoabilidade e desproporcionalidade nas sanções.

4.2. Não será feita análise sobre ocorrência ou não da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e ressarcitória da Tribunal de Contas da União, consoante dispositivos da Resolução TCU 344/2022, que regulamenta a Lei 9.873/1999 quanto a essa matéria, haja visto que esse exame foi realizado na instrução da AudContratações (peça 298, p. 29-31), de modo apropriado.

5. ***Ausência de dolo, falha grave ou erro grosseiro***

5.1. Ambos os recorrentes defendem a tese de que não há elementos que indiquem condutas negligentes, imprudentes, culpa grave ou erro grosseiro. As suas atuações teriam sido de acordo com padrões aceitáveis de diligência e cuidado esperados de um gestor público ou de um "homem médio".

5.2. Eles argumentam, em síntese, que:

a) a jurisprudência do TCU está convergindo para o entendimento de que "erro grosseiro" é uma conduta que se desvia do padrão de diligência exigido de um "gestor médio" (peça 355, p. 5-6 e 17-21, e peça 359, p. 5-6 e 17-21);

b) não há qualquer evidência de que os recorrentes tenham atuado em desconformidade com a lei ou de maneira que se desviasse significativamente do padrão do "gestor médio" (peça 355, p. 5-6 e 17-21, e peça 359, p. 5-6 e 17-21);

c) para a imposição de multa, é pacífico o entendimento segundo o qual é exigida a demonstração clara de que o agente público praticou erro grosseiro, em estrita observância à teoria dos motivos determinantes (peça 355, p. 5-7, e peça 359, p. 5-7);

d) consoante procedimentos estabelecidos pelo Decreto 5.450/2005, não houve qualquer desvio no padrão procedimental do Departamento de Logística em Saúde, muito menos ingerência da Sra. Adriane Maria Pignatti nos atos praticados desde a publicação do edital (peça 355, p. 6-17);

e) a habilitação dos licitantes seguiu a ordem de classificação, conforme art. 25 do Decreto 5.450/2005, em que a empresa Precisa foi chamada pelo fato de a vencedora (MS Bastos) ter sido inabilitada e a segunda colocada (F.B.M. Indústria Farmacêutica Ltda) ter desistido, após várias suspensões e reabertura do pregão (peça 355, p. 6-13);

f) a empresa Precisa foi convocada para apresentar documentos de habilitação em 10/10/2018, sendo que sua análise ocorreu entre os dias 10/10/2018 e 30/10/2018, período em que não existia impedimento da empresa Global Gestão em Saúde S/A (peça 355, p. 13-15, e peça 359, p. 13-15);

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77660553.

g) não há orientação no Decreto 5.450/2005 para que se consulte o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf) de licitantes antes do seu chamamento para a fase de habilitação, razão pela qual a verificação da habilitação dos licitantes ocorreu somente após a convocação para o envio de documentos de habilitação, como decorrência do princípio da celeridade (peça 355, p. 14-16, e peça 359, p. 14-16);

h) a participação do Sr. Gustavo Apoliano Mesquita somente se deu em 17/7/2018, às 16h08, isto é, 7 dias após a abertura do Pregão SRP 53/2018, que se deu em 10/7/2018, o que exime a sua responsabilidade por não ter feito consulta no Sicaf de todos os licitantes antes do início do procedimento licitatório;

i) a participação da Sra. Adriane Maria Pignatti somente se deu em 22/11/2018, quando homologou o Pregão SRP 53/2018, sendo que quando assinou a ata de registro de preços 115/2018, em 29/11/2018, se encontravam juntadas aos autos três declarações Sicaf referentes à empresa Precisa, sem qualquer histórico de impedimento indireto de licitar (peça 355, p. 15-16);

j) há nos autos declaração Sicaf da empresa Precisa, emitida em 5/10/2018 (peça 184), na qual não consta o campo de "Ocorrências Impeditivas Indiretas", apesar de o documento ter sido emitido na vigência do período de suspensão de licitar da empresa Global (10/7/2018 a 9/10/2018) (peça 359, p. 15-16);

k) o sistema de compras da época (PEC) foi desativado, o que vem inviabilizando a demonstração de que, à época da convocação para a apresentação de documentos de habilitação, foram tomadas todas as medidas de conferência da situação da empresa Precisa no Sicaf (peça 355, p. 15-16, e peça 359, p. 16-17);

l) não foi a Sra. Adriane Maria Pignatti quem determinou a publicação do Pregão SRP 53/2018, mas o então Diretor do Departamento de Logística em Saúde (DLOG), Sr. Tiago Pontes, em 9/5/2018, quem também emitiu aviso à empresa Global sobre a penalidade de suspensão do direito de participar de licitação, em 29/6/2018 (peça 355, p. 16-17);

m) não houve qualquer desvio no padrão procedimental do DLOG ou da Sra. Adriane Maria Pignatti durante o curso do referido procedimento licitatório, com (i) o recebimento da documentação de habilitação, (ii) suspensão do pregão para envio da documentação para a área técnica (Departamento da AIDS), e (iii) reabertura do pregão após a análise técnica, com decisão pela habilitação ou inabilitação da licitante convocada a apresentar documentos (peça 355, p. 16-17).

n) a verificação da qualificação técnica de certames voltados à aquisição de insumos estratégicos para a saúde no Ministério da Saúde é responsabilidade das áreas técnicas recorrentes do processo licitatório (peça 355, p. 18-22, e peça 359, p. 18-22);

o) ao se analisar os requisitos técnicos previstos nos itens 7.1, 7.2 e 7.3 do Termo de Referência do Pregão SRP 53/2018, em atendimento à diligência do pregoeiro do DLOG, por meio da Tarefa T67 do PEC 21913, foi emitido parecer no sentido de que os documentos de habilitação técnica apresentados atendiam tecnicamente às exigências do Termo de Referência (peça 355, p. 18-20, e peça 359, p. 18-20);

p) o processo seguiu o fluxo institucional adequado, pelo qual a análise dos requisitos de qualificação técnica é de responsabilidade da área técnica especializada, especialmente em temas sensíveis que envolvem normas sanitárias e regulamentações específicas, não inexistindo erro grosseiro dos recorrentes (peça 355, p. 21-22, e peça 359, p. 21-22);

q) o entendimento de que a verificação da habilitação técnica dos licitantes deve ser realizada pelos pregoeiros, e não pela área técnica recorrente do processo de aquisição,

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77660553.

contraria as melhores práticas de governança, particularmente no que tange à segregação de funções (peça 355, p. 20-21, e peça 359, p. 20-21).

Análise:

5.3. Os recorrentes invocam a ausência de dolo, falha grave ou erro grosseiro, conforme disposição do art. 28 do Decreto-lei 4.657/1942 (LINDB), introduzido pela Lei 13.655/2018. Esse é um tema que tem sido progressivamente integrado nos julgamentos do TCU, com o objetivo de detalhar as ações individuais e avaliar as penalidades aplicadas.

5.4. A jurisprudência do TCU tem igualado o conceito de "erro grosseiro" ao de "culpa grave" para fins do exercício do poder sancionatório. Tem-se considerado como erro grosseiro o que resulta de grave inobservância do dever de cuidado e zelo com a coisa pública, vide Acórdãos 2391/2018-TCU-Plenário, rel. Min. Benjamin Zymler, 2.924/2018-TCU-Plenário, rel. Min. José Mucio Monteiro, 11.762/2018-TCU-2ª Câmara, rel. Min. Marcos Bemquerer, bem como Acórdãos 957/2019, 1.264/2019 e 1.689/2019, todos do Plenário, rel. Min. Augusto Nardes.

5.5. Sobre a definição de "erro grosseiro", o Min. Antônio Anastasia argumentou ser mais adequado interpretá-lo como "culpa grave", "mas mantendo o referencial do homem médio" (Acórdão 2012/2022-TCU-2ª Câmara). Assim, caracteriza-se como erro grosseiro a ação do administrador que comete um grave equívoco em situações em que um indivíduo com diligência ordinária não falharia, levando em conta os desafios e obstáculos existentes no momento da realização do ato questionado (art. 22 da LINDB).

5.6. No caso em tela, as irregularidades decorrentes de declarar a empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda vencedora de licitação e homologar o seu resultado, sem que ela tivesse apresentado documentos exigidos no Edital, e desconsiderando o artifício utilizado para burlar penalidade aplicada Global Gestão em Saúde S/A – agravadas pela aceitação de "carta de fiança fidejussória" emitida pela empresa Fib Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A – violam dispositivos normativos e entendimentos jurisprudenciais.

5.7. O então vigente Decreto 5.450/2005, em seus art. 11, incisos IV e VI, e art. 25, bem como os itens 11.10 e 13 do Edital do certame (peça 296, p. 101-108) estabelecem que compete ao pregoeiro verificar os documentos de habilitação da licitante e que todos os demais documentos de qualificação técnica teriam sido considerados conformes e aceitos pelo responsável.

5.8. O art. 27, caput e § 2°, do Decreto 5.450/2005 ainda estabelece que a autoridade competente somente homologará o procedimento licitatório após constatada a regularidade dos atos praticados, inclusive com as condições de habilitação consignadas no edital.

5.9. A despeito da responsabilidade de autoridade que homologou a licitação, a jurisprudência recente do Tribunal de Contas da União tem considerado que ela pode se isentar de responsabilidade apenas em caso de vícios ocultos, dificilmente perceptíveis:

> *A autoridade homologadora é responsável solidariamente pelos vícios identificados nos procedimentos licitatórios, exceto se forem ocultos, dificilmente perceptíveis. A homologação se caracteriza como ato de controle da autoridade competente sobre todos os atos praticados na respectiva licitação. Esse controle não pode ser tido como meramente formal ou chancelatório, mas como ato de fiscalização. (Acórdão 368/2022-TCU-Plenário, rel. Min. Jorge Oliveira, e Acórdão 505/2021-TCU-Plenário, rel. Min. Marcos Bemquerer)*
>
> *A autoridade homologadora é solidariamente responsável pelos vícios identificados nos procedimentos licitatórios, exceto se forem vícios ocultos, dificilmente perceptíveis. A homologação se caracteriza como um ato de controle praticado pela autoridade*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77660553.

> *competente, que não pode ser tido como meramente formal ou chancelatório. (Acórdão 4843/2017-TCU-Primeira Câmara, rel. Min. José Mucio Monteiro)*

5.10. É de se citar que o Sr. Gustavo Apoliano Mesquita, em suas justificativas, afirmou que a penalidade de suspensão no direito de licitar e contratar com o Ministério da Saúde tinha prazo apenas antes do início da fase de negociação (peça 174, p. 3):

> *Segundo **Relatório de Ocorrências Ativas do SICAF**, página 3, referente à empresa GLOBAL GESTÃO EM SAÚDE S.A., CNPJ: 10.375.666/0001-88, consta a penalidade de **SUSPENSÃO do direito de licitar e contratar com o Ministério da Saúde** pelo prazo de **10/07/2018** até o dia **09/10/2018** (DOC 34). Considerando que a negociação com a empresa PRECISA iniciou-se em 10/10/2018, ou seja, um dia após o vencimento da penalidade, e que a proposta da empresa só foi aceita em **31/10/2018**, não haveria óbice para participação da mesma no certame em questão, conforme mensagens, em destaque no chat, nas páginas 8 e 16 da Ata complementar 1 (DOC 24). (grifos originais)*

5.11. Esse argumento – que indica que o pregoeiro tinha ciência do fato – foi replicado nos recursos ora analisados, em que os recorrentes afirmam que a empresa Precisa foi convocada para apresentar documentos de habilitação em 10/10/2018, momento em que não existia impedimento da empresa Global Gestão em Saúde S/A (peça 355, p. 13-15, e peça 359, p. 13-15).

5.12. No entanto, não há como se conceber o entendimento de que as condições de habilitação sejam aplicadas apenas no momento da apresentação das propostas, pois a efetiva participação dos licitantes se inicia com o registro de sua proposta no sistema eletrônico. Independentemente do momento em que foram solicitados ou analisados os documentos de habilitação, eles deveriam demonstrar a aptidão das empresas em participar/ingressar no certame.

5.13. É de se citar que a penalidade à empresa Global Gestão em Saúde S/A foi aplicada pelo próprio Departamento de Logística em Saúde em 29/6/2018, retificada em 2/7/2018 (peça 294, p. 2-3), e a proposta da empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda ocorreu em 6/7/2018, sendo a sessão de abertura do Pregão Eletrônico SRP 53/2018 em 10/7/2018 (peça 199) – ou seja, os eventos foram quase concomitantes.

5.14. A informação de que a Global Gestão em Saúde S/A detinha mais de 99% do capital social da Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda poderia ser facilmente obtida mediante consulta ao credenciamento da Precisa no Sicaf, cujos dados foram informados pelo próprio Sr. Francisco Emerson Maximiano, e também no documento de alteração do contrato social da Precisa, que foi apresentado como documento de habilitação da licitante no Pregão Eletrônico SRP 53/201

5.15. Ademais, conforme já ressaltado pela AudContratações, desde 8/6/2015 o Sicaf possui funcionalidade que emite alerta da existência de "ocorrências impeditivas indiretas do fornecedor", que são resultado de cruzamento de informações sobre o quadro societário das empresas, e que visa evitar burla à penalidade de declaração de inidoneidade, impedimento de contratar ou licitar com a Administração Pública ou suspensão temporária de licitar com a Administração (peça 298, p. 21).

5.16. Ressalta-se ainda que os problemas relacionados à habilitação técnica se referem à não apresentação de documentos previstos no item 12.7 do Edital, descritos no item 7 do Termo de Referência (peça 294, p. 67), a saber:

> *7.1. Licença de Funcionamento ou Alvará Sanitário emitida pela Vigilância Sanitária Estadual e/ou Municipal em nome da licitante, com indicação da validade do documento;*
>
> *7.2. Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) participante da licitação emitida pela Anvisa, com indicação da validade do documento; e*
>
> *7.3. Registro do Produto emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa ou publicação do registro no Diário Oficial da União em nome da licitante. Se a licitante for*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77660553.

> *distribuidora ou importadora, deverá apresentar a autorização expressa do detentor do registro, para comercialização e/ou distribuição do produto em âmbito nacional. Será permitida ainda a apresentação de protocolo de pedido de revalidação do registro junto à Anvisa, desde que tenha sido requerido nos termos do § 6º do artigo 12 da Lei 6.360/76, em nome da licitante*

5.17. Não se trata do descumprimento de especificações técnicas, que demandem elevado conhecimento especializado, como referentes a normas sanitárias e regulamentações específicas (que poderiam invocar responsabilidade de área técnica recorrente), mas sim a ausência de documentos de habilitação, que poderiam ser facilmente observados com uma conferência do processo. Não se trata "de vícios dificilmente perceptíveis", como os responsáveis fazem parecer em seus recursos.

5.18. O Ministro Vital do Rêgo, em seu voto, destacou que se os recorrentes tivessem se atentado para as disposições do Edital do Pregão Eletrônico SRP 53/2018, eles teriam identificado a inviabilidade de a Precisa com a Global participarem do certame (peça 308, p. 4):

> *12.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros (...).*
>
> *(...)*
>
> *12.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.*
>
> *(...)*
>
> *12.1.7. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação. (grifos acrescidos)*

5.19. Depreende-se, portanto, que a conduta dos recorrentes se distanciou daquela que seria esperada, revelando inobservância no dever de cuidado no trato com a coisa pública, num claro exemplo ao que alude o art. 28 da LINDB (vide Acórdãos 1.689/2019-TCU-Plenário, rel. Min. Augusto Nardes, 2.924/2018- TCU-Plenário, rel. Min. José Mucio Monteiro, e 2.391/2018-TCU-Plenário, rel. Min. Benjamin Zymler).

5.20. Por fim, o fato de a Sra. Adriane Maria Pignatti não ter determinado a publicação do Pregão SRP 53/2018, ou não ter emitido aviso à empresa Global sobre a penalidade de suspensão do direito de participar de licitação, não a exime de responsabilidade por atos da DLOG no período que foi diretora da unidade. Reforça-se que a referida penalidade foi retificada pelo departamento em 2/7/2018 (peça 194, p. 3), oito dias antes da sessão de abertura do pregão eletrônico (peça 199, p. 5).

5.21. O Tribunal de Contas da União entende que o fato de um gestor ocupar um determinado cargo por determinado período de tempo não o exime de responsabilidade pelos atos então praticados – ainda que com boa-fé:

> *O agente público responde por todos os atos praticados no exercício do cargo que ocupa, mesmo em função de substituto temporário. (Acórdão 2.453/2008-TCU-Plenário, rel. Min. Marcos Vinicios Vilaça)*
>
> *A condição de substituto não exime o gestor de responsabilidade, haja vista que, para ocupar a função, ainda que por poucos dias, o gestor deve contar com qualificação,*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77660553.

conhecimento e demais atributos necessários, o que pressupõe a capacidade de tomar decisões. (Acórdão 877/2016-TCU-1ª Câmara, rel. Min. Benjamin Zymler)

5.22. Não é necessária a comprovação de má-fé (dolo) para que haja a responsabilização de um agente público, mas apenas da ausência de boa-fé objetiva, que é o fato de se seguir as normas pertinentes, os preceitos e os princípios gerais do direito (Acórdãos 7.936/2018-TCU-2ª Câmara, rel. Min. Augusto Sherman, e 13.732/2019-TCU-1ª Câmara, rel. Min. Walton Alencar Rodrigues)

5.23. Assim sendo, sugestiona-se rejeitar os argumentos trazidos, de modo a eximir os recorrentes de responsabilidade no Acórdão 1.912/2024-TCU-Plenário, rel. Min. Vital do Rêgo.

6. ***Quebra de isonomia em relação a condutas de outro agente***

6.1. Ambos os recorrentes defendem a tese de que as suas penas deveriam ser excluídas, dado que houve uma indevida diferenciação de tratamento entre os agentes que atuaram no Pregão SRP 53/2018 e no Pregão SRP 81/2018.

6.2. Eles argumentam, em síntese, que:

a) no âmbito do Pregão SRP 81/2018, o TCU entendeu que o pregoeiro, Sr. Pablo Guedes de Andrade Fenelon, também falhou em aferir a adequabilidade dos documentos apresentados pela empresa Precisa, em atendimento aos itens 7.1, 7.2 e 7.3 do Termo de Referência (peça 355, p. 22-23, e peça 359, p. 22-23);

b) apesar da igualdade entre os procedimentos adotados no Pregões SRP 53/2018 e SRP 81/2018, não houve aplicação de penalidade para o pregoeiro Pablo Guedes de Andrade Fenelon, que atuou neste último (peça 355, p. 22-23, e peça 359, p. 22-23);

c) em homenagem ao princípio da isonomia, ambos os recorrentes também merecem ter a sua pena excluída (peça 355, p. 22-23, e peça 359, p. 22-23).

<u>Análise:</u>

6.3. São diferentes as irregularidades apuradas no Pregão SRP 53/2018 e no Pregão SRP 81/2018. Em relação a este último, a AudContratações propôs acolher as razões e justificativas do pregoeiro quanto à apresentação dos documentos exigidos pelo item 13.12 do Edital, descritos no item 7 do Termo de Referência, especificamente, os documentos indicados nos itens 7.2 e 7.3.

6.4. Vide matriz de responsabilização, as irregularidades relacionadas à Sra. Adriane Maria Pignatti e ao Sr. Gustavo Apoliano Mesquita foram:

cometimento de fraude à licitação, pois a participação da empresa Precisa Comercialização de Medicamentos (CNPJ: 03.394.819/0005-00) no Pregão Eletrônico SRP 53/2018 constituiu mero artifício utilizado pelo senhor Francisco Emerson Maximiano (CPF: 094.378.048-93) para burlar a penalidade aplicada à Global Gestão em Saúde S.A. (CNPJ 10.375.666/0001-88 – NIRE 35300436601) que, à época, estava suspensa para licitar e contratar com o Ministério da Saúde. Ademais, a licitante declarada vencedora não comprovou deter qualificação técnica, vez que não foram localizados no processo SEI 25000.203531/2018-11 os seguintes documentos exigidos pelo item 12.7 do Edital, descritos no item 7 do Termo de Referência: "7.1. Licença de Funcionamento ou Alvará Sanitário emitida pela Vigilância Sanitária Estadual e/ou Municipal em nome da licitante, com indicação da validade do documento; 7.2. Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) participante da licitação emitida pela ANVISA, com indicação da validade do documento e 7.3. Registro do Produto emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA ou publicação do registro no Diário Oficial da União em nome da licitante. Se a licitante for distribuidora ou importadora, deverá apresentar a autorização expressa do detentor do registro, para comercialização

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77660553.

> *e/ou distribuição do produto em âmbito nacional. Será permitida ainda a apresentação de protocolo de pedido de revalidação do registro junto à ANVISA, desde que tenha sido requerido nos termos do § 6º do artigo 12 da Lei 6.360/76, em nome da licitante.*

6.5. Por outro lado, a irregularidade relacionada ao Sr. Pablo Guedes de Andrade Fenelon não contemplou o cometimento de fraude de licitação por participação de empresa suspensa para licitar:

> *habilitação da empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0005-00), filial de Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555), cuja denominação atual é OVS Importadora Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555), declarada vencedora do item 1 do Pregão Eletrônico SRP 81/2020, sem que a licitante houvesse comprovado deter qualificação técnica, nos termos estabelecidos pelo Edital/Termo de Referência.*

6.6. No caso, a documentação referente à qualificação técnica no Pregão SRP 81/2018 não foi apresentada somente a prevista no item 7.1 do Termo de Referência (Licença de Funcionamento ou Alvará Sanitário emitida pela Vigilância Sanitária Estadual e/ou Municipal). No caso do Pregão SRP 53/2018, além dessa, foram não foram apresentadas as previstas nos itens 7.2 (Autorização de Funcionamento de Empresa) e 7.3 (Registro do Produto).

6.7. Embora o voto do relator, Min. Vital do Rêgo, realmente não tenha previsto isenção de responsabilidade do Sr. Pablo Guedes de Andrade Fenelon – o Ministro destacou anuir com as multas propostas pela unidade técnica –, suas justificativas foram expressamente aceitas pelo Plenário, no item 9.10 do Acórdão 1.912/2024, rel. Min. Vital do Rêgo.

6.8. É de se frisar que a opinião da unidade instrutora não vincula o posicionamento do colegiado de Ministros, que pode decidir de maneira diversa, com base em sua própria avaliação dos fatos e do direito aplicável, ainda que eventualmente se concorde com o mérito da proposta. Nesse contexto, pode-se citar

> *A proposta alvitrada pela Unidade Técnica não vincula o posicionamento do Ministro-Relator e tampouco o do colegiado de Ministros (Acórdão 1399/2008-TCU-Plenário, de relatoria do Min. Raimundo Carreiro).*
>
> *A opinião da unidade instrutora e o parecer do Ministério Público, por sua vez, não vinculam o relator, que pode, ou não, adotar as análises técnicas como razões de decidir. (Acórdão 78/2017-TCU-Plenário, relatado pelo Ministro Bruno Dantas).*

6.9. Assim sendo, sugestiona-se rejeitar os argumentos trazidos pelos recorrentes, de modo a não eximi-los de responsabilidades no Acórdão 1.912/2024-TCU-Plenário, rel. Min. Vital do Rêgo.

7. ***Desarrazoabilidade e desproporcionalidade nas sanções***

7.1. Ambos os recorrentes defendem a tese de que o julgado condenatório aplicou sanções em rigor excessivo, sem um cotejamento adequado com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando critérios para aplicação de sanções previstos no art. 22, §§ 1º e 2º, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB).

7.2. Eles argumentam, em síntese, que:

> *a) apesar de o TCU ter entendido que a inacessibilidade dos sistemas de compras da época (PEC e SINProcesso) não configura cerceamento de defesa, tal circunstância atenua a responsabilidade dos recorrentes (peça 355, p. 25);*
>
> *b) as declarações emitidas no Sicaf, ao tempo da homologação e da assinatura da Ata de Registro de Preços 115/2018, não apresentavam ocorrências de impedimentos indiretas*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77660553.

para licitar, circunstância que também atenua as responsabilidades (peça 355, p. 25, e peça 359, p. 25);

c) os históricos funcionais de ambos os recorrentes demonstram a ausência de informações que desabonem a sua conduta funcional (peça 355, p. 25, e peça 359, p. 25-26);

d) a Sra. Adriane Maria Pignatti, ao tempo da homologação do Pregão SRP 53/2028, exercia a função de diretora substituta, não sendo ela a autoridade que emitiu o aviso de suspensão de licitar para a Global (peça 355, p. 25-26);

e) o Sr. Gustavo Apoliano Mesquita exerceu a função de pregoeiro por mais de 10 anos com dedicação e competência, conduzindo 27 pregões em 2017 e 38 em 2018, sempre com zelo e rigor, não responde a mais nenhum processo relacionado aos pregões ou contratações de que tenha participado (peça 359, p. 25-26);

f) não houve qualquer imputação de débito no âmbito da fiscalização, restando objeto contratado cumprido, o que indica que a homologação do Pregão SRP 53/2018 não causou dano ao erário (peça 355, p. 26, e peça 359, p. 26);

g) as sanções são desproporcionais e desarrazoadas quando comparadas às penas aplicadas às empresas Global Gestão em Saúde S.A. e OVS Importadora Ltda. (atual denominação da empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda.) (peça 355, p. 26-27, e peça 359, p. 26-27)

h) as multas representam um valor muito superior à remuneração básica bruta dos recorrentes, colocando em risco as suas subsistências e as de suas famílias (peça 355, p. 26-27, e peça 359, p. 26-27)

i) há precedentes do TCU no sentido de que, mesmo diante do reconhecimento da responsabilidade do agente público, deixa-se, excepcionalmente, de imputar-lhe pena de multa ou de inabilitação, quando as circunstâncias do caso concreto assim autorizarem (peça 355, p. 27-28, e peça 359, p. 27-28)

Análise:

7.3. As multas imputadas tiveram fundamento no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 268, inciso II, do Regimento Interno (RI) do TCU, que estabelece que as penalidades podem oscilar entre cinco e cem por cento de R$ 82.654,54, definido no art. 1º da Portaria TCU 7/2024, vigente à época do acórdão condenatório. As sanções descritas no item 9.2 do referido julgado (R$ 30.000,00) correspondem a 36,3%, desse montante.

7.4. Conforme Acórdãos 1.308/2019-TCU-2ª Câmara, de relatoria do Min. Marcos Bemquerer, e 3.259/2020-TCU-Plenário, de relatoria do Min. André de Carvalho, há certa discricionariedade do TCU na aplicação de multas, devendo-se buscar como balizadores o nível de gravidade dos ilícitos, a valoração das circunstâncias fáticas e jurídicas e a isonomia de tratamento com casos análogos, não havendo rol de agravantes e atenuantes legalmente reconhecido.

7.5. Ainda que se considere as circunstâncias atenuantes trazidas pelos recorrentes, não se observa um percentual abusivo na multa interposta. Conforme ponderado no voto do relator, Min. Vital do Rêgo (peça 306, p. 5), as irregularidades cometidas na admissão de empresa impedida de licitar e sem a qualificação técnica exigida, foram graves e grosseiras, uma vez que favoreceram vultosa contratação de fornecedor inepto, e deixaram de observar regras editalícias evidentes.

7.6. A proposta da unidade técnica ainda considerou circunstância agravante para fins de apenação, referente à aceitação da "carta de fiança fidejussória" CON 41072018 emitida pela empresa Fib Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A (CNPJ: 23.706.333/0001-36) para atender

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77660553.

à obrigação estabelecida na Cláusula Sétima do Contrato 249/2018, resultante do Pregão Eletrônico SRP 53/2018 e Ata de Registro de Preços 115/2018.

7.7. É importante esclarecer que, quando há débito, não se adota os parâmetros fixados no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 268, inciso II, do RI/TCU (multa decorrente de grave infração a norma legal ou regulamentar), mas sim a do art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c art. 267 do RI/TCU, em que a penalidade pode oscilar entre cinco e cem por cento do valor atualizado do dano.

7.8. Os recorrentes alegam que sanções são desproporcionais e desarrazoadas quando comparadas às penas aplicadas às empresas. Todavia, o TCU entende que não pode aplicar a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 a pessoas jurídicas, vez que não é possível fazer uma análise da conduta em se tratando de empresas. Os seguintes enunciados abordam esse tema:

> *A multa decorrente de grave infração a norma legal ou regulamentar (art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992) é inaplicável a pessoa jurídica, uma vez que essa pena requer análise da conduta do agente que praticou o ato tido como irregular. Somente é cabível aplicação de multa a pessoa jurídica quando verificada ocorrência de débito (art. 57 da Lei 8.443/1992). (Acórdão 6708/2020-Segunda Câmara, rel. Min. Augusto Nardes)*
>
> *A aplicação da multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 requer análise da conduta do agente que praticou o ato tido como irregular. Não há como fazer avaliação de conduta em se tratando de pessoa jurídica. Só cabe a aplicação de multa a pessoa jurídica quando verificada a ocorrência de débito (art. 57 da Lei 8.443/1992). (Acórdão 638/2014-Primeira Câmara, rel. Min. Augusto Sherman)*
>
> *Não é cabível a aplicação de multa a pessoa jurídica com fundamento no art. 58 da Lei 8.443/1992, pois essa sanção pecuniária é destinada a agentes públicos e particulares que atuam como gestores de recursos públicos, a exemplo de dirigentes de entidades privadas convenentes. Somente é cabível aplicação de multa a pessoa jurídica quando verificada a ocorrência de débito (art. 57 da referida lei). (Acórdão 10314/2023-Primeira Câmara, rel. Min. Benjamin Zymler)*

7.9. Ademais, consoante o Acórdão 2011/2007-TCU-1ª Câmara, de relatoria do Min. Augusto Nardes, a baixa remuneração do responsável, ou o comprometimento da renda, não afasta a incidência de sanção ou a sua culpabilidade pela prática de atos irregulares, sendo aos responsáveis facultado o parcelamento da multa, acrescida dos encargos legais.

7.10. Esse posicionamento é ratificado pelos enunciados dos Acórdãos 3248/2015-TCU-1ª Câmara, de relatoria do Min. Benjamin Zymler, 670/2017-TCU-2ª Câmara, de relatoria da Min. Ana Arraes, 2442/2019-TCU-Plenário, de relatoria do Min. Walton Alencar Rodrigues, e 3346/2022-TCU-1ª Câmara, de relatoria do Min. Vital do Rêgo, que estabelecem que a hipossuficiência financeira não impede a aplicação de multa:

> *Alegações de hipossuficiência financeira, idade avançada e doença grave não impedem a imputação de débito ou a aplicação de multa a responsável. No âmbito do TCU, é possível o parcelamento das dívidas em razão de situação econômica desfavorável do devedor.*

7.11. Por fim, não se observa no caso em concreto situações fáticas ou jurídicas que justificam deixar-se de imputar as penas de multa ou de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, consoante art. 60 da Lei 8.443/1992.

7.12. Os recorrentes não refutaram a existência de fraude à licitação no Pregão Eletrônico SRP 53/2018, e as alegações de ausência de falha grave ou erro grosseiro, de quebra de isonomia em relação à conduta de outro responsável, e de ausência de dano não se mostram suficientes para afastar as penalidades a eles impostas.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77660553.

7.13. Assim sendo, considerando os parâmetros definidos no arts. 58, inciso II, e 60 da Lei 8.443/1992 c/c art. 268, inciso II, do RI/TCU art. 1º da Portaria TCU 36/2023, e as irregularidades praticadas, não se observa desproporcionalidade na aplicação das sanções aplicadas.

CONCLUSÃO

8. Do exame, é possível concluir que:

a) a jurisprudência do TCU tem igualado o conceito de "erro grosseiro" ao de "culpa grave" para fins do exercício do poder sancionatório, como o que resulta de grave inobservância do dever de cuidado e zelo com a coisa pública;

b) o art. 11, incisos IV e VI, e o art. 25 então vigente Decreto, bem como nos itens 11.10. e 13 do Edital do certame estabelecem que compete ao pregoeiro verificar os documentos de habilitação da licitante e que todos os demais documentos de qualificação técnica teriam sido considerados conformes e aceitos pelo responsável;

c) o art. 27, caput e § 2°, do Decreto 5.450/2005 estabelece que a autoridade competente somente homologará o procedimento licitatório após constatada a regularidade dos atos praticados, inclusive com as condições de habilitação consignadas no edital;

d) a homologação se caracteriza como um ato de controle praticado pela autoridade competente, que não pode ser tido como meramente formal ou chancelatório;

e) independentemente do momento em que foram solicitados ou analisados os documentos de habilitação, eles deveriam demonstrar a aptidão das empresas em participar/ingressar no certame;

f) a penalidade à empresa Global Gestão em Saúde S/A foi aplicada pelo DLOG em 29/6/2018, retificada em 2/7/2018, e a data da sessão de abertura do Pregão Eletrônico SRP 53/2018 ocorreu poucos dias após, em 10/7/2018;

g) a informação de que a Global Gestão em Saúde S/A detinha mais de 99% do capital social da Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. poderia ser obtida mediante consulta ao Sicaf, que desde 8/6/2015 possui funcionalidade que emite alerta da existência de "ocorrências impeditivas indiretas do fornecedor";

h) a ausência de documentos de habilitação poderia ser facilmente observada com uma conferência do processo, não se tratando "de vícios dificilmente perceptíveis";

i) a condição de substituto não exime o gestor de responsabilidade, haja vista que, para ocupar a função, o gestor deve contar com qualificação, conhecimento e demais atributos necessários, o que pressupõe a capacidade de tomar decisões;

j) a opinião da unidade instrutora não vincula o posicionamento do colegiado de Ministros, que pode decidir de maneira diversa, com base em sua própria avaliação dos fatos e do direito aplicável;

k) há certa discricionariedade do TCU na aplicação de multas, devendo-se buscar como balizadores o nível de gravidade dos ilícitos, a valoração das circunstâncias fáticas e jurídicas e a isonomia de tratamento com casos análogos;

l) ainda que se considere as circunstâncias atenuantes trazidas pelos recorrentes, não se observa um percentual abusivo nas sanções interpostas;

m) a multa decorrente de grave infração a norma legal ou regulamentar é inaplicável a pessoa jurídica, uma vez que essa pena requer análise da conduta do agente que praticou o ato tido como irregular;

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77660553.

n) a baixa remuneração do responsável, ou o comprometimento da renda, não afasta a incidência de sanção ou a sua culpabilidade pela prática de atos irregulares, sendo facultado aos responsáveis o parcelamento da multa, acrescida dos encargos legais;

o) os recorrentes não refutaram a existência de fraude à licitação no Pregão Eletrônico SRP 53/2018, e as alegações apresentadas não se mostram suficientes para afastar as penalidades a eles impostas.

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

9. Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo-se, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992:

a) conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento;

b) informar aos recorrentes e demais interessados do acórdão a ser proferido, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77660553.

VOTO

Tratam os autos de pedido de reexame interposto pelo Sr. Gustavo Apoliano Mesquita e pela Sra. Adriane Maria Pignatti, então pregoeiro e Diretora-Substituta do Departamento de Logística em Saúde do Ministério da Saúde, respectivamente, contra o Acórdão 1.912/2024-TCU-Plenário, da relatoria do E. Ministro Vital do Rêgo.

Originalmente, trata-se de representação autuada para apurar indícios de irregularidades em contratos objeto da "CPI da Pandemia", em especial, os contratos do Ministério da Saúde em que a FIB Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A figurava como garantidora, tendo em vista suspeitas de a empresa contar com capital social fictício.

Na oportunidade, o Tribunal identificou irregularidades na condução e homologação dos Pregões Eletrônicos SRP 53/2018 e SRP 81/2020, na formalização, gestão e fiscalização dos Contratos 249/2018, 152/2019 e 316/2020, e na aceitação de garantia na forma de carta de fiança fidejussória apresentada pela FIB Bank no âmbito do Contrato 29/2021.

Os recorrentes, pregoeiro e Diretora-Substituta do Departamento de Logística em Saúde do Ministério da Saúde, foram multados e inabilitados para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, em razão de habilitação indevida da empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. no Pregão Eletrônico SRP 53/2018, por falhas na análise da documentação comprobatória da qualificação técnica, bem como pela participação em fraude à licitação no certame, uma vez que a empresa era controlada por outra empresa impedida de contratar com a Administração Pública, a Global Gestão em Saúde S/A.

Irresignados, interpuseram os recursos ora em análise, nos quais alegam ausência de dolo, falha grave ou erro grosseiro; quebra de isonomia em relação a conduta de outro agente e aplicação de sanções desproporcionais.

A AudRecursos concluiu por conhecer e negar provimento aos apelos.

Passo a decidir.

Conheço do recurso, tendo em vista preencher os requisitos dos artigos 48, 32 e 33 da Lei 8.443/1992.

No mérito, cinge-se à controvérsia a respeito da irregularidade da conduta dos recorrentes em declarar a Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. vencedora de licitação e homologar o seu resultado, desconsiderando o artifício utilizado para burlar penalidade aplicada à Global Gestão em Saúde S/A, sua controladora, e sem que a Precisa tivesse apresentado todos os documentos exigidos no instrumento convocatório.

Em relação à primeira irregularidade, o fato de não existir impedimento da empresa Global Gestão em Saúde S/A, em 10/10/2018, data em que a empresa Precisa foi convocada para apresentar os documentos, após ter se sagrado vencedora, não socorre aos responsáveis.

A penalidade à sócia foi aplicada pelo próprio Departamento de Logística em Saúde em 29/6/2018, com validade entre 10/7/2018 e 9/10/2018. A proposta da empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda foi apresentada em 6/7/2018 e a sessão de abertura do Pregão Eletrônico SRP 53/2018 ocorreu em 10/7/2018, quando a Global Gestão em Saúde S/A estava formalmente impedida de licitar com a Administração Pública.

A proximidade das referidas datas é significativo indício de que os recorrentes tinham ou deveriam ter o conhecimento da penalidade aplicada à Global Gestão em Saúde S/A, especialmente

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77660884.

porque o dia de abertura do certame coincide com o do início da penalidade aplicada pelo próprio departamento condutor da licitação.

Consta no voto condutor do acórdão recorrido a informação de que a empresa Global era conhecida no Departamento de Logística do Ministério da Saúde por práticas que levaram à aplicação de diversas penalidades.

No que diz respeito à relação comercial entre as duas empresas, a informação de que a Global Gestão em Saúde S/A detinha mais de 99% do capital social da Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. poderia ser facilmente obtida mediante consulta ao Sicaf e no documento de alteração do contrato social da Precisa, apresentado como documento de habilitação.

Nesse cenário, considerando de amplo conhecimento daquele Departamento do Ministério da Saúde que a Global Gestão em Saúde S/A estava impedida de licitar e contratar com a Administração Pública, bem como que ela detinha expressiva participação acionária na Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda., era absolutamente exigível aos recorrentes que cumprissem as regras fixadas no edital no seguinte sentido:

> 12.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros (...).
>
> 12.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

Para além dessa irregularidade, os recorrentes aceitaram a documentação apresentada pela Precisa desacompanhada da regular autorização de funcionamento de empresa e da autorização do detentor do registro para comercialização e distribuição do produto.

Não procede a alegação de responsabilidade da área técnica quanto às irregularidades atinentes aos documentos apresentados, pois não diziam respeito ao descumprimento de especificações técnicas, que demandavam elevado conhecimento especializado, como referentes a normas sanitárias e regulamentações específicas, mas sim à verificação das condições de participação e conferência dos documentos apresentados, competência dos recorrentes, segundo o Decreto 5.450/2005 e o edital do certame.

A decisão recorrida apontou que a autorização de funcionamento da empresa e o detentor do registro apresentados se referiam à Precisa Matriz e não à Precisa Filial, participante da licitação. Ademais a autorização aludia à medicamentos, e não "produtos correlatos", classificação dada, entre outros, aos preservativos femininos, objetos do Pregão 53/2018.

Depreende-se, portanto, que as condutas dos recorrentes se distanciaram das que seriam esperadas, revelando certa inobservância no dever de cuidado com a coisa pública.

O fato de a Sra. Adriane ocupar o cargo em substituição e não ter participado da aplicação e comunicação do impedimento à Global Gestão em Saúde não exime sua responsabilidade, pois, ao aceitar exercer o cargo temporariamente, assumiu que contava com atributos e conhecimentos necessários para os atos que praticou, segundo vasta jurisprudência desta Casa.

Não é necessária a comprovação de má-fé (dolo) para que haja a responsabilização de agente público no TCU, mas apenas a presença de culpa simples, decorrente do fato de não terem sido observadas as normas pertinentes, os preceitos e os princípios gerais do direito.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77660884.

As condutas identificadas como irregulares no Pregão SRP 81/2018 foram diferentes das atribuídas aos recorrentes. Naquele certame, não restou comprovado o cometimento de fraude à licitação, mas falha na Licença de Funcionamento (item 7.1 do termo de referência) apresentada, atenuada pelo fato de consultas ao sistema de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo informarem licença sanitária vigente para a empresa participante.

No Pregão SRP 53/2018, foram observadas irregularidades na aceitação da Licença de Funcionamento ou Alvará Sanitário, na autorização de funcionamento de empresa e no registro do produto emitido pela Anvisa (itens 7.1, 7.2 e 7.3 do termo de referência).

Quanto ao alegado tratamento diferenciado em relação às empresas faltosas, esclareço que o Tribunal não aplica a multa prevista no artigo 58 da Lei 8.443/1992 a pessoas jurídicas, uma vez que não é possível fazer análise acerca da conduta de empresas. Somente é cabível aplicação de multa a pessoa jurídica quando verificada ocorrência de débito (art. 57 da Lei 8.443/1992), o que não ocorreu no presente caso.

Sobre o processo, tive a oportunidade de receber o jovem pregoeiro em meu gabinete que expôs, de forma minudente, as várias dificuldades que teve no processamento da licitação, bem como as dificuldades em relação ao prazo e ao funcionamento do órgão, em vista da transitória ausência de pessoal habilitado na repartição. Foi incumbido, por decisão administrativa, do processamento da licitação, sem nenhum preparo anterior, o que lhe acarretou imensas dificuldades, sobretudo em relação aos prazos exigidos.

A evidência dessas dificuldades consta no extrato da sessão pública do certame (peças 198 e 199), no qual é possível observar que o ora responsável foi designado pregoeiro após o início do certame, provavelmente sem as informações prévias acerca dos atos administrativos já praticados, as quais condicionaram a ação do agente, em dar prosseguimento à situação até então existente.

Mesmo assim, atuou de forma diligente para sanar as dúvidas sobre a regularidade da habilitação apresentada pela empresa licitante, ao solicitar documentos adicionais e requisitar análise especializada da área técnica do Ministério da Saúde.

Essas circunstâncias, definidas no art. 22 do Decreto-Lei 4.657/1942 (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro), impõem a redução das penalidades impostas ao gestor, cuja conduta não se reveste do grau de reprovabilidade necessário para a manutenção da inabilitação e da multa no patamar inicialmente fixado.

Embora possa considerar razoáveis e proporcionais a inabilitação pelo prazo mínimo legal de cinco anos e a aplicação de multas correspondentes a 36,3% do montante previsto no artigo 58 da Lei 8.443/1992, levo, no caso concreto, em consideração a hipótese de que problemas de toda ordem permitiram, no caso concreto, o equivocado processamento da licitação em exame.

Portanto, conheço dos pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 1.912/2024-TCU-Plenário, por Adriane Maria Pignatti, para, no mérito, negar-lhe provimento, e por Gustavo Apoliano Mesquita, para dar-lhe parcial provimento, para excluir a inabilitação e reduzir a multa para 10% do valor previsto no artigo 58 da Lei 8.443/1992.

Com essas considerações, voto para que o Tribunal adote a minuta de acórdão que ora submeto ao Colegiado.

TCU, Sala das Sessões, em 10 de setembro de 2025.

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Relator

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77660884.

ACÓRDÃO Nº 2111/2025 – TCU – Plenário

1. Processo nº TC 028.814/2022-3.
2. Grupo II – Classe de Assunto: I – Pedido de Reexame (Representação)
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde (); Banco Central do Brasil (00.038.166/0001-05); Convida Refeições Ltda (05.599.283/0001-53); Departamento de Polícia Federal (00.394.494/0014-50); Fib Bank Garantia de fianças Fidejussórias S/A (23.706.333/0001-36); Global Gestão Em Saúde S/A. (10.375.666/0001-88); P.B. Investment Empresarial S/A (07.376.572/0001-19); Precisa - Comercialização de Medicamentos Ltda (03.394.819/0001-79); Presta Construtora e Serviços Gerais Ltda (02.282.245/0001-84); Procuradoria da República No Distrito Federal - MPF (26.989.715/0012-65); Secretaria-Executiva da Controladoria-Geral da União; Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde (00.394.544/0173-12).
3.2. Responsáveis: Adriane Maria Pignatti (666.542.461-87); Fib Bank Garantia de fianças Fidejussórias S/A (23.706.333/0001-36); Global Gestão Em Saúde S/A. (10.375.666/0001-88); Gustavo Apoliano Mesquita (893.810.331-53); P.b. Investment Empresarial S/A (07.376.572/0001-19); Precisa - Comercialização de Medicamentos Ltda (03.394.819/0001-79); Roberto Ferreira Dias (086.758.087-98).
3.3. Recorrentes: Adriane Maria Pignatti (666.542.461-87); Gustavo Apoliano Mesquita (893.810.331-53)..
4. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações).
8. Representação legal: Jose Orismo Pereira (134315/OAB-SP), representando Fib Bank Garantia de fianças Fidejussórias S/A; Felipe Carvalho de Novaes (37173/OAB-PE), representando Tiago Pontes Queiroz; Fábio Nunes Bandeira de Melo (4331/OAB-AM), Bruno Vieira da Rocha Barbirato (6975/OAB-AM) e outros, representando Adele Schwartz Benzaken; Pablo Rangell Mendes Rios Pereira (40586/OAB-DF), representando Gustavo Apoliano Mesquita; Anderson de Oliveira Lima Goncalves, Renata Rita Volcov (274717/OAB-SP) e outros, representando Convida Refeições Ltda; Daiana Lacerda de Morais Melo Praxedes (31531/OAB-GO) e Jeane Cristina Machado (27245/OAB-GO), representando Presta Construtora e Serviços Gerais Ltda; Pablo Rangell Mendes Rios Pereira (40586/OAB-DF), representando Adriane Maria Pignatti.

9. Acórdão:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Adriane Maria Pignatti e Gustavo Apoliano Mesquita contra o Acórdão 1.912/2024-TCU-Plenário, relator E. Ministro Vital do Rêgo;

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em:

9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Adriane Maria Pignatti para, no mérito, negar-lhe provimento;

9.2. conhecer do pedido de reexame interposto por Gustavo Apoliano Mesquita, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, excluindo a inabilitação e determinando a redução da multa para 10% do valor previsto no artigo 58 da Lei 8.443/1992; e

9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77660751.

10. Ata n° 36/2025 – Plenário.
11. Data da Sessão: 10/9/2025 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2111-36/25-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator), Aroldo Cedraz, Antonio Anastasia e Jhonatan de Jesus.
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti e Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)
BRUNO DANTAS
na Presidência

(Assinado Eletronicamente)
WALTON ALENCAR RODRIGUES
Relator

Fui presente:

(Assinado Eletronicamente)
CRISTINA MACHADO DA COSTA E SILVA
Procuradora-Geral

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77660751.